

1500514-06.2021.8.26.0627

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PABLO RODRIGO PALARO DE CAMARGO

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Polícia, noticiando a prática do tráfico de drogas pelo denunciado, demonstram que FABRÍCIO tinha em depósito a droga para posterior entrega ao consumo de terceiros (tráfico de drogas).

A acusação ofereceu a denúncia em 27/10/2021(Denúncia).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia por meio de defensor dativo, reservando-se ao direito de alegar as teses de defesa em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio - SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500514-06.2021.8.26.0627 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500514-06.2021.8.26.0627

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO GABRIEL DA SILVA

Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de FABRICIO GABRIEL DA SILVA, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006, pelo seguinte fato:

Consta do incluso inquérito policial que, em dia 1º de outubro de 2021, às 7h, na Rua D, 138, Cohab Chis, nesta cidade e Comarca de Teodoro Sampaio, FABRÍCIO GABRIEL DA SILVA, qualificado à fl. 5, para fins de tráfico, tinha em depósito e guardava 6 (porções) porções de de Erythroxylum Coca L, na forma de pedra ("crack"), com peso aproximado de 1,05g (um grama e cinco centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 13, auto de constatação de fl. 15 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 91/93, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com "denúncias" recebidas pelos policiais, o imóvel, localizado no endereço referido acima, estava sendo utilizado pelo denunciado para a prática de tráfico de drogas.

Após a realização de diligências preliminares, e com a finalidade de apurar a veracidade da "denúncia", foi expedido mandado de busca e apreensão para a residência (autos nº 1500505-44.2021.08.26.0627).

Ao ingressarem no imóvel, os policiais encontram o denunciado deitado sobre um sofá disposto na sala. Realizadas buscas na residência, lograram encontrar e apreender as seis porções de "crack" que estavam ocultas sob o referido sofá.

A quantidade e as demais circunstâncias da prisão em flagrante, assim como as informações recebidas pela Polícia, noticiando a prática do tráfico de drogas pelo denunciado, demonstram que FABRÍCIO tinha em depósito a droga para posterior entrega ao consumo de terceiros (tráfico de drogas).

A acusação ofereceu a denúncia em 27/10/2021(Denúncia).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia por meio de defensor dativo, reservando-se ao direito de alegar as teses de defesa em memoriais.

Rejeitou-se a referida defesa e recebeu-se a denúncia 29/11/2021(Denúncia).

Não havendo qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução.

Na audiência de instrução, colheram-se as declarações de Márcio Thomazin dos Santos, Henrique Fernandes Moraes e Breno Henrique da Silva. Ainda, interrogou-se FABRÍCIO GABRIEL DA SILVA.

Em alegações finais, o Ministério Público relatou o feito e afirmou que é o caso de procedência; que há materialidade às fls. 91/93, indicando se tratar de crack; que a autoria é inconteste pelos depoimentos sob o crivo do contraditório; que a testemunha Márcio esclareceu que havia operação policial; que havia diversas denúncias de que o tráfico era praticado no local; que, na busca e apreensão no 1500-04; que o réu disse que morava com o réu Breno e com a avó; que o réu negou que as drogas pertenciam a ele; que as drogas foram encontradas na casa do réu e o informante Breno afirmou que o réu morava na residência e usava drogas; que o réu negou até isso; que a versão do réu é contraditória; que as drogas não podiam ser destinadas ao uso já que o réu negou isso, então estavam destinadas ao tráfico; que não há que se falar em desclassificação para uso; que, na primeira fase, cabe aumento pelos maus antecedentes; que, na segunda fase, há que se aplicar a reincidência; que, na terceira fase, há comprovação de dedicação à atividade criminosa (terceira vez que é preso por furto).

A defesa pede a desclassificação do crime do art. 33 para o crime do art. 28, mesmo o réu afirmando não fazer o consumo em casa;

É o relatório.

Fundamentação

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à análise do mérito.

Diz o art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O tipo objetivo, portanto, consiste na prática de qualquer dos verbos (bastante um) acima expostos com substância definida na Portaria SVS/MS n. 344/1998. Tratando-se de tipo misto alternativo, basta a prática da conduta descrita em um único verbo. Já o art. 28 da mesma lei diz:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

A prova da materialidade é indubitosa. Está no auto de exibição e apreensão de fl. 13, auto de constatação de fl. 15 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 91/93. Também às fls. 5 e ainda em juízo, o irmão do réu relatou que ele é usuário. No que toca à autoria, a testemunha Márcio Thomazin dos Santos, Policial Militar, disse que participou de uma operação conjunta com a polícia civil; busca e apreensão em residência; que o cão indicou aos policiais que poderia ter entorpecentes onde o indivíduo estava dormindo; que os policiais levantaram o sofá; que, quando entraram na residência, ele disse que não havia entorpecente; que depois que encontraram as drogas, se calou; que só encontraram os entorpecentes. O informante Breno Henrique da Silva, irmão do réu, afirmou que ficou sabendo quando chegou na delegacia que o irmão tinha sido pego; que o irmão é usuário; que estava na casa que ele; que estava presente na busca e apreensão; que ele usa tudo, todo tipo de droga; que nunca viu tráfico no local; que usa diariamente; que ele tentou parar mas voltou de novo; que estava o tempo todo em casa; que os separaram; que não viu cachorro; que estava no quarto; que não conseguia ver o que acontecia na sala.

A testemunha Henrique Fernandes Moraes, Policial civil, esclareceu que é investigador em Epitácio; que foram convocados para apoio em Teodoro Sampaio; que as equipes foram distribuídas; que foram juntos à casa do Fabrício; que deram cumprimento no mandado de busca; que tentaram manter o local para que ninguém tivesse acesso; que estava o irmão também; que estava dando mais apoio para a polícia militar que ia comparecer com o canil; que aguardaram o cão chegar para fazer uma vistoria na casa; que assim que o cão começou a prestar o serviço, foi localizada uma porção de entorpecente debaixo do sofá; que o Fabrício estava dormindo; que o sofá ficava na sala; que as drogas foram encontradas pelo cão; que foram convocados para dar apoio porque tinha bastante residência para ser cumprida para dar o mandado de busca; que só garantiram que ninguém mudasse nada; que entrou na casa; havia o irmão e a avó; que o irmão mostrou que o réu estava dormindo na sala; que, no momento que disseram que iam fazer busca, ele disse que não tinha nada de ilícito na casa; que do que se lembra, só apreenderam só a droga e celular; que não se lembra como a droga estava embalada.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, alegou que os policiais chegaram; que viu as viaturas; que a vó estava dentro de casa; que a vó avisou; que pediu para abrir a porta; que ela abriu a porta; que o delegado caparroz perguntou se tinha droga, bomba ou revólver; que pediram para colocar a mão para trás; algemaram e colocaram fora da residência; que começaram a vasculhar a casa; que perguntaram se não tinha droga de novo, e ele negou; que falaram que ia esperar o procedimento do canil; que, nesse procedimento do canil, não sabe o que aconteceu que o colocaram dentro da viatura; que ficou separado do irmão Breno; que não sabe da existência da droga, que não tem como assumir droga que não é dele; que é usuário de drogas; que usa crack maconha e cocaína; que só usava droga quando pegava pouca quantidade; que permanecia tranquilo; que tinha momentos que pretendia parar; que usava até três porções por dia; que essa droga não era para ele usar porque, se não, assumiria; que moravam ele, o irmão e a vó; que o irmão usa maconha e a vó não usa droga; que o irmão não trafica; que a droga não era dele nem para uso; que não levava droga em casa; utilizava onde comprava;

A versão do réu fantasiosa e beira o absurdo. Nega até o que os próprios familiares

admitem: que era usuário frequente de drogas. Mas os elementos dos autos são suficientes para mostrar que a droga foi localizada em sua casa. Ambos os policiais foram unânimes em esclarecer que a droga foi encontrada embaixo do sofá onde o réu estava dormindo, por um cachorro. e o próprio réu esclareceu que as demais pessoas da casa não faziam uso de crack. não há, pois, como se imputar o entorpecente a qualquer outra pessoa que não o réu. Ainda, se o próprio réu era tão usuário como seu irmão disse e como ele próprio, com dificuldade, confessou, seria pouco usual não ter qualquer tipo de droga em sua residência.

É certo, portanto, que o delito ocorreu e foi praticado pelo réu.

Ainda, estão presentes todos os elementos do tipo objetivo. Isso porque

A tipicidade objetiva está parcialmente provada. O laudo toxicológico indicou a substância como sendo maconha cocaína. E tal consta da Portaria SVS/MS n. 344/1998. No que toca à mercancia, há indícios de mercancia, mas não prova. Às fls. 99 e seguintes, consta a perícia de seu celular. Ali, constam apenas duas conversas, com indicações indiciárias da existência de tráfico. Uma pessoa perguntando "quem tem", que parece indicar alguém perguntando quem tem droga (o que não prova que o réu estava comercializando o entorpecente) e outra perguntando "tem uma onda por aí não?". Tal frase também serve de indício do comércio de entorpecentes, mas não de prova. o contexto é suficiente para indicar que falavam de droga, mas não há como saber se se tratava de consumidor ou amigo.

Ainda, nenhum dos policiais ouvidos em juízo soube precisar informações sobre a razão pela qual o mandado de busca e apreensão era ali cumprido, atestando apenas a veracidade da diligência.

Também a quantidade encontrada é compatível tanto com o uso como o tráfico. E não foram encontrados elementos acessórios (como papelotes, balanças); e dinheiro.

Assim, é possível até afirmar que o réu traficava drogas. Mas, para uma condenação, especialmente de pena tão gravosa quanto o tráfico, essa afirmação tem que se basear em um conjunto robusto de provas. Aqui, há um conjunto duvidoso de indícios, que deve ser resolvido em favor do réu.

No que toca aos antecedentes do réu, servem para justificar prisões preventivas, tornar a pena maior ou impedir o acesso a benefícios penais. Mas não podem ser utilizados para definir se o réu cometeu ou não o fato criminoso. Assim, o fato de o réu já ter sido anteriormente condenado pelo crime de tráfico não faz presumir que o objetivo da referida droga era o comércio.

Reitero: a história contada pelo réu não é crível. Mas as alegações da denúncia no que toca ao tráfico não estão cabalmente provadas.

Não havendo provas, mas apenas indícios, de que a droga se destinava ao comércio, em pro do réu deve-se presumir que se destinava ao uso. Assim, promovo a desclassificação para o crime do art. 28 da LD.

O crime se consumou porque é de mera conduta.

Houve dolo. Isso porque o ato foi praticado com consciência e vontade de agir.

Presente, portanto, tipicidade subjetiva.

Houve violação do bem jurídico protegido pela norma, qual seja saúde pública, considerando a natureza e quantidade da droga. Presente, pois, a tipicidade material.

Presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento realizado pelo réu. Isso se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes desses elementos do conceito analítico de crime.

Enfim, comprovada a materialidade e autoria do fato, essa recaindo sobre o réu FABRICIO GABRIEL DA SILVA; sendo típica a conduta de guardar substância entorpecente para consumo próprio, capitulada no art. 28, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006; e não militando em favor dele qualquer circunstância que exclua o crime ou o isente de pena, imperativa a condenação.

O réu é reincidente, nos termos dos arts. 63 e 64 do CP (art. 61, I, CP).

Dosimetria da pena

Nos termos do art. 68 do CP, passo a fixar a pena do réu para o crime cometido.

O grau de reprovabilidade da conduta é normal à espécie delitiva, sendo normal a culpabilidade. Quanto aos antecedentes, presentes (fls. 155/157, duas condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico anteriormente ao fato). Não há elementos hábeis para avaliar sua conduta social e sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto. Quanto aos motivos, são os usuais para o tipo. As circunstâncias do crime não militam em desfavor do réu. As consequências do delito são as que já se encontram abarcadas no tipo em questão. Não há que se falar em vitimologia neste caso. A quantidade das substâncias era suficiente para caracterizar o uso, mas comum para tal tipo de conduta. A droga tinha natureza excepcional (crack).

Em razão da existência de antecedentes, deixo de aplicar a pena do inciso I, escolhendo a pena do inciso II. Presente a circunstância da natureza, fixo a pena em 10 meses de prestação de serviços (anotando que o limite, no caso, é de 10 meses, já que há reincidência específica, na forma do art. 28, § 4º, da Lei Federal n. 11.343/2006).

Sem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a pena final em 10 de prestação de serviço, a ser decidido no juízo da execução penal.

Arbitro multa de 40 dias-multa para o caso de não realização da prestação.

Fixo o valor da pena de multa em 1/30 do salário-mínimo, em razão da ausência de elementos em sentido diverso.

Sem substituição ou sursis, já que não se trata de pena privativa de liberdade.

Pela mesma razão, deixo de fixar regime de cumprimento.

Quanto à detração, deverá ser realizada no juízo da execução criminal. Caso contrário, haverá violação do princípio da individualização penal, do juiz natural (que é o juízo da execução) e da isonomia. O regime inicial tem de ser fixado segundo a pena definitiva, não devendo ser influenciado pela prisão provisória. Nesse sentido, a colenda 16ª Câmara de Direito Criminal (Embargos de Declaração Criminal 0009370-15.2016.8.26.0625; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Foro de Taubaté - 3ª Vara Criminal; j. em: 17/8/2018)

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da denúncia para condenar o réu na pena do art. 28 da Lei de Drogas consistente em 10 meses de prestação de serviços.

De maneira a não violar o princípio da homogeneidade, revogo a prisão preventiva, já que incompatível com a condenação aqui prolatada. Expeça-se alvará de soltura, se por outra razão não estiver preso.

Incabível indenização mínima ou a comunicação da sentença à vítima, porque não há vítima específica.

Quanto ao celular, deixo de decretar seu perdimento em favor da União, já que, apesar de utilizados como instrumento para a prática do crime, não constituem produto de fabricação ilícita (art. 91, II, a, do CP). Se assim transitar em julgado a sentença, devem ser devolvidos ao réu.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por agora, aguardando a fase de interposição de recursos.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas, porque se fosse processado pelo crime do art. 28 da LD, o feito teria tramitado no Juizado Especial, onde não há custas.

Determino a destruição das drogas, se isso ainda não foi feito. Oficie-se à Delegacia de Polícia Civil, se necessário.

Comunique-se à Justiça Eleitoral.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Cumpra-se, no mais, o que dispõe as Normas de Serviço Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo.

Ciência ao Ministério Público e à defesa dativa, em audiência.

P., r. e i..

Teodoro Sampaio, 17 de fevereiro de 2022.

Pablo Rodrigo Palaro de Camargo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA